

1501152-13.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL DAMIÃO DA ROCHA FILHO e outro

Data da Audiência:

26/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501152-13.2021.8.26.0571 - Controle 2021/001216

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL DAMIÃO DA ROCHA FILHO e outro

Data da Audiência:

26/05/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, do Defensor, o advogado Eduardo Capelin Kagawa, OAB 342870/SP e dos Acusados Manoel Damião da Rocha Filho e Cleber Souza Santos. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Leandro Ortiz de Camargo e Juliano Seabra arroladas pelas partes. Em seguida os réus foram interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, Os réus foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", e artigo 61, II, "j", ambos do CP, pois, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 16 horas e 10 minutos, na praça de pedágio localizada na Rodovia Raposo Tavares, km 135, bairro Floresta, cidade de Sarapuí, nesta Comarca de Itapetininga, conluiados e agindo em concurso e com

unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e transportavam, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a) 04 (quatro) porções de crack, com peso líquido de 0,60g (sessenta centigramas); b) 50 (cinquenta) porções de cocaína, com peso líquido de 34,06g (trinta e quatro gramas e seis centigramas), e; c) 03 (três) porções de maconha, com peso líquido de 21,33g (vinte e um gramas e trinta e três centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram notificados e apresentaram defesas prévias (fls. 173/176 e 189/190). A denúncia foi recebida em 02/02/2022 (fls. 193) e em 07/03/2022 (fls. 203/204). MANOEL foi citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu advogado, motivo pelo qual, em relação a ele, o processo e o prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366 do CPP (fls. 225/226). Após, MANOEL foi localizado e pessoalmente citado (fls. 256), assim como CLÉBER (fls. 237). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 21/22) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 233/236). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 05 e 06). Interrogados em Juízo, o réu CLÉBER afirmou que parte da droga lhe pertencia, mas era destinada ao uso. Metade das drogas lhe pertencia. As drogas na cidade onde residia, Arandu, eram muito caras. A despeito do combustível e do pedágio, compensava rodarem cerca de 240 km para adquiri-las em Itapevi. O réu MANOEL disse que metade das drogas apreendidas lhe pertencia. Ela era destinada ao seu uso. Negou, todavia, o uso de "crack". Não soube explicar o motivo pelo qual dirigiu-se até Itapevi para adquirir os entorpecentes. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-los. De fato, diz a denúncia que na data dos fatos, os acusados passavam pela praça de pedágio acima mencionada, instante em que CLEBER, condutor do veículo "GM Astra GL", placas "DEM 0734 - Arandu (SP)", demonstrou extremo nervosismo, pois deixou cair todo o dinheiro que tinha em mãos para pagar a tarifa. Tal atitude suspeita culminou na abordagem pela Polícia Rodoviária que efetuava blitz de rotina no local. Durante a diligência, os policiais encontraram no interior do veículo as porções das drogas acima mencionadas, todas devidamente embaladas e prontas para a imediata alienação. Com os acusados foram encontrados, ainda, dois aparelhos de telefone celular e quantia de R\$60,00 (sessenta reais). Os acusados foram presos e conduzidos a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial rodoviário Leandro afirmou que fazia ação de fiscalização junto ao pedágio, quando o veículo ocupado pelos réus encostou no guichê do pedágio. Ambos apresentaram extremo nervosismo, ao ponto do pagador do tributo deixar com que o dinheiro caísse no chão. Isso motivou a abordagem. Nessa ocasião, foram encontradas as porções das drogas mencionadas na denúncia. Foi dito que a droga pertencia, de forma fracionada, a ambos. O policial Juliano fez coro às palavras do seu colega. Acrescentou que as drogas foram encontradas no porta-luvas do veículo. A droga, segundo disse CLÉBER, pertencia a ambos. Assim, a prova é firme ao incriminar os acusados. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. É de se notar que a variedade de drogas, principalmente, dá forte testemunho no sentido do tráfico. De mais a mais, o fato de rodarem cerca de 240 km para adquirirem drogas para consumo é inverossímil e não convence. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que os réus não ostentam Maus antecedentes e são primários (fls. 39/41 e 42/45). Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime inicial poderá ser fixado no aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos bens e valores apreendidos. Dada a palavra à Defensoria Pública, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa os interesses do réu Manoel,

que foi denunciado e está sendo processado como artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c. c. artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu foi preso apenas – de acordo com os depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, desde a abordagem policial, o réu, juntamente com o corréu, esclareceu que o entorpecente apreendido era para seu uso. Ambos disseram que foram até a cidade de Itapevi comprar entorpecentes e que iriam dividir entre si, sendo que cada um consumiria metade. Esclareceram que na cidade em que residiam o entorpecente era caro, motivo pelo qual se deslocaram de carro para a compra. Com eles não foram encontrados apetrechos para o tráfico, anotações, não houve perícia em celular e nada que indicasse a traficância. Ainda, eles não foram vistos em contato com nenhuma pessoa e em situação que indicasse a traficância. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico "para consumo pessoal". Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus

requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse

legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida". (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente

identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) Na segunda fase de dosimetria da pena deverá ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, c) seja afastada a agravante pleiteada na denúncia, visto que o estado de pandemia em nada contribuiu ou influenciou para a prática do crime; d) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixado regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, ante a primariedade do réu e em conformidade com os arts. 33, 44 e 59 do Código Penal; e) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETININGA/SP. CLEBER SOUZA DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos do processo de número em epígrafe, através de seu advogado e bastante procurador que ao final se identifica e assina, com endereço profissional indicado no rodapé, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Como já consta do boletim de ocorrência, afirmado pelo acusado Cleber, esse faz uso de drogas e a droga apreendida era para seu uso próprio. Diante do próprio testemunho, percebe-se sua boa-fé em assumir a responsabilidade. Ademais, segundo os relatos obtidos no inquérito policial, não há qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, uma vez que não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga, dinheiro em grande escala, etc. Desta maneira, conclui-se que o indiciado apenas se encontrava em seu veículo trafegando em direção a sua cidade, pois fora comprar a droga de seu consumo em outra Comarca. Visto isso, considerando-se os depoimentos dos aludidos policiais militares, não há, nem de longe, qualquer importe fático que conduza à figura do tráfico de drogas ilícitas. Cumpre ressaltar que a quantidade de droga apreendida seria para uso de ambos os acusados. Desta feita, todos os depoimentos colhidos na fase inquisitória traduzem que os acusados tão-somente compraram drogas para uso próprio, sem um terceiro ou outro propósito de traficar. Confirma-se isso com a manifestação positiva do r. Ministério Público com o Acordo de Não Persecução Penal. Por fim, todo o demonstrado até o presente momento elucida a verdade dos fatos, e que ao fim restará provado. Diante de todo o exposto, requer-se: A) A concessão dos BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98, do CPC e do artigo 1º da Lei nº 5.478/1968, por não ter este, condições de prover as despesas processuais sem comprometer diretamente seu sustento; B) Subsidiariamente, a aplicação do TRÁFICO PRIVILEGIADO, conforme previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; C) A aplicação do regime inicial ABERTO; D) O réu não possui maus antecedentes, ou seja, primários, sendo de rigor a aplicação das condições favoráveis da pena; E) A liberação do veículo GM ASTRA, em favor de seu proprietário, CLEBER. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CLEBER SOUZA DOS SANTOS e MANOEL DAMIÃO DA ROCHA FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o art. 29, "caput", e o art. 61, inc. II, alínea "J", ambos do Código Penal, porque, no dia 23 de setembro de 2021, em período de anormalidade - Pandemia, por volta das 16 h e 10 min, na Praça de pedágio localizado na Rodovia Raposo Tavares, km 135, Bairro Floresta, na Cidade de Sarapuí, nesta Comarca de Itapetininga, traziam consigo, guardavam e transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro porções de "crack", com peso de 0,60 gramas; cinquenta porções de "cocaína", com peso de 34,06 gramas; e três porções de "maconha", com peso de 21,33 gramas. O Réu Cleber Souza constituiu Defensor, o qual apresentou pedido para designação de nova data para usufruir o benefício de acordo de não persecução penal, fls. 148/149, o MP anuiu ao pedido, fls. 155. O Réu Manoel Damião foi notificado por edital, fls. 169. O Acusado Cleber Souza foi notificado, fls. 170, e apresentou defesa preliminar, fls. 173/176. O Réu Manoel Damião, igualmente, apresentou sua defesa, fls. 189/190. A denúncia foi recebida em face do

Acusado Manoel Damião, fls. 193, o qual foi citado mediante edital, fls. 202. O Réu Cleber Souza não aceitou os termos propostos, assim a denúncia foi recebida, fls. 203/204. O Órgão Acusador requereu a decretação da prisão preventiva do Réu Manoel Damião, fls. 222, o pedido foi acolhido, fls. 225/226. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 239/244, e a seguir o Réu foi citado pessoalmente, fls. 256. A Dra. Defensora do Réu Manoel Damião reiterou os termos da defesa preliminar e requereu a liberdade provisória, fls. 260/261, o MP opinou favoravelmente ao pedido, fls. 265, o pedido de liberdade deferido, fls. 266/267. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas, seguindo-se o interrogatório dos Acusados (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e as Defesas, as desclassificações. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 10/12, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, bem como no Laudo de Constatação, fls. 21/22 e de Exame químico-toxicológico n. 278.400/2021, fls. 233/236, contatando-se a presença dos princípios ativos Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína. Leandro Ortiz de Camargo e Juliano Seabra, policiais militares, disseram que estavam no pedágio, quando viram o motorista do veículo nervoso ao ponto de derrubar o dinheiro no chão ao ver os policiais. Deram ordem ao condutor e, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, no porta-luvas do veículo, encontraram as porções de drogas. O Réu Cléber disse que metade dos entorpecentes lhes pertencia e a outra metade era de Manoel. Tinham ido de Arandu a Itapevi para buscar as drogas. Manoel Damião da Rocha Filho, Réu, ao ser interrogado, disse que metade das drogas lhe pertence e se destinavam ao seu uso. Foi a Itapevi porque, onde morava, os entorpecentes são caros. Cléber Souza dos Santos, Réu, ao ser interrogado, disse que metade das drogas lhe pertencem e se destinavam ao seu uso. Foi a Itapevi porque, onde morava, os entorpecentes são caros. O "crack" não lhe pertencia, apenas usa "cocaína" e "maconha". Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando viram os réus no interior do veículo e o motorista, visivelmente nervoso, derrubou o dinheiro no chão ao pagar o pedágio. Feita a vistoria veicular, no porta-luvas os policiais encontraram quatro porções de "crack", com peso de 0,60 gramas; cinquenta porções de "cocaína", com peso de 34,06 gramas; e três porções de "maconha", com peso de 21,33 gramas, drogas que, pela quantidade, diversidade e número de porções, destinavam-se ao tráfico de entorpecentes. Ademais, não é crível que os acusados tenham saído de Arandu para comprar drogas em Itapevi, distante cerca de 240 km, apenas para buscar drogas para uso pessoal. Ainda que em Arandu os preços estejam inflacionados, existem outras opções, como Avaré, entre outras cidades. Assim, o tempo e o dinheiro gastos com a compra também apontam a finalidade mercantil. Deve ser decretada a perda do dinheiro, obtido por meio ilícito, pois evidenciada a dedicação ao tráfico de entorpecentes, bem como do veículo apreendido, uma vez que foi empregado para aquisição e transporte de entorpecentes de Itapevi para Arandu. Por fim, os policiais deram testemunhos firmes, coerentes, e descreveram de forma isenta os fatos como ocorreram. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de

ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas. CLEBER SOUZA DOS SANTOS: - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. O Réu confessou, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, DJe 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. MANOEL DAMIÃO DA ROCHA FILHO: - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu confessou, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. - Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar CLEBER SOUZA DOS SANTOS e MANOEL DAMIÃO DA ROCHA FILHO, qualificados nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos valores apreendidos. Decreto a perda do veículo apreendido. Defiro a liberação dos celulares. Deixo de condenar os Réus nas custas, ante a pobreza presumida. Os Réus responderam em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderão interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 26 de maio de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA